

NORASHIKIN BINTI ABU SAID
LWN.
MAHIYAR BIN NASIR

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 21 Oktober 2021 bersamaan 14 Rabiul Awal 1443H]

Rayuan No. 10000-041-0160-2018
(Rayuan terhadap keputusan Bantahan Awal)

Pegum Syarie Pemohon: Mohd Reza bin Mohd Rafie daripada Chambers of Rafie Mohd Shafie & Associates

Pegum Syarie Responden: Muhammad Hafiz bin Ab Rashid daripada Tetuan Hafiz Nuaaim & Partners

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini merupakan suatu rayuan terhadap keseluruhan keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 5 Disember 2018 berkaitan kes permohonan Bantahan Awal melalui Saman No. 10300-041-0435-2018. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah menolak permohonan Perayu dan memerintahkan bahawa kos ditanggung oleh masing-masing.

2) Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Perayu(Pemohon) telah memfailkan Notis Rayuan pada 17 Disember 2018 dan mengemukakan empat (4) Alasan Rayuan pada 18 Disember 2019, bahawa:

2.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf atas isu kausa tindakan kerana keputusannya bertentangan dengan arus keterangan iaitu isu pernikahan Perayu dan Responden telahpun difaraqkan dan Responden

mengetahui dan percaya rukun nikah iaitu wali tak dipenuhi melalui **Ekshibit NAS-3**.

- 2.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mengambil kira iqrar/syahadah dan qarinah Responden bahawa Responden telah berpakat dengan sindiket sijil nikah terbang.
- 2.3 YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mengambil kira syahadah dan qarinah Pemohon melalui **Ekshibit NAS-2** yang menunjukkan Pemohon tidak pernah memfailkan permohonan wali hakim di Ipoh, Perak.
- 2.4 YA Hakim Bicara telah tersalah arah apabila tidak membatalkan/menolak kes induk harta sepencarian sejajar dengan niat Responden yang “hanya memerlukan surat” dan sanggup membuat apa sahaja tanpa mengikut Hukum Syarak. Keputusan YA Hakim Bicara bertentangan dengan arus keterangan dan undang-undang Seksyen 122, 25 dan 26 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

FAKTA KES

- 4) Perayu dan Responden telah berkahwin pada 4 Februari 1990 dan pada 7 Julai 2014, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat melalui Saman No. 10005-010-2138-2013 telah mensabitkan bahawa pernikahan antara Perayu dan Responden adalah tidak sah mengikut Hukum Syarak kerana tidak memenuhi rukun wali. Perayu dan Responden telah diperintahkan faraq nikah oleh Hakim Bicara.

- 5) Pada 16 Jun 2016 Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian melalui Saman No. 10300-017-0387-2016.
- 6) Pada 29 Jun 2018, Perayu telah memfailkan Permohonan Bantahan Awal melalui Permohonan No. 10300-041-0435-2018.
- 7) Pada 5 Disember 2018, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah menolak permohonan Bantahan Awal tersebut dan memerintahkan pihak-pihak menanggung kos masing-masing.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

8) Dalam rayuan ini, Perayu telah membuat penghujahan secara sekaligus dengan merujuk kepada Alasan Rayuan Pertama hingga Empat. Berdasarkan penelitian kami terhadap Alasan Rayuan dan Hujah Perayu, kami mendapati bahawa Alasan Rayuan Kedua, Ketiga dan Keempat adalah melibatkan dakwaan yang belum diputuskan oleh Mahkamah, malahan dakwaan-dakwaan tersebut adalah tersasar daripada isu utama yang menjadi persoalan di peringkat bantahan. Selain daripada itu **Ekshibit NAS-2 dan NAS-3** yang dirujuk untuk menyokong dakwaan adalah berbeza dengan apa yang terdapat dalam **rekod rayuan muka surat 11-15**. Kami juga mendapati bahawa dakwaan-dakwaan tersebut adalah melibatkan persoalan fakta yang tidak sesuai dibangkitkan di peringkat bantahan. Oleh yang demikian, alasan-alasan rayuan tersebut adalah ditolak dan kami akan memberi fokus ulasan kepada isu utama sahaja iaitu sama ada Responden tidak ada kausa tindakan untuk memfailkan tuntutan harta sepencarian disebabkan Perayu dan Responden tidak pernah bercerai tetapi difarakkan oleh Mahkamah.

9) Dalam rayuan ini Perayu berhujah bahawa Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tidak mempunyai bidangkuasa untuk mendengar/membicarakan tuntutan Responden kerana bertentangan dengan undang-undang dan Hukum Syarak. Peruntukan Seksyen 122(1) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menjadi asas dalam tuntutan Responden adalah tidak terpakai terhadap tuntutan Responden memandangkan Perayu dan Responden bukan suami isteri yang sah dan mereka tidak pernah bercerai. Pernikahan mereka telah difaraqkan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat pada 7 Julai 2014. Perayu menegaskan bahawa faraq nikah adalah pemisahan kehakiman, bukannya perceraian dan bagi sesuatu pernikahan yang difaraqkan maka pernikahan itu tidak wujud dari awal lagi memandangkan rukun pernikahan tidak dipenuhi. Oleh itu, Responden tiada kausa tindakan untuk memfailkan kes induk harta sepencarian kerana Perayu dan Responden bukan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai.

10) Responden pula secara ringkasnya, dalam membidas hujah Perayu telah menegaskan bahawa:

- 10.1 Keputusan YA Hakim Bicara adalah betul, tepat dan tidak berlaku kekhilafan kerana tidak bertentangan dengan mana-mana nas Hukum Syarak, malah ia selaras dengan kaedah

الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

"Pada asasnya, sesuatu itu kekal mengikut keadaan asalnya".

- 10.2 Perayu gagal membuktikan elemen Hukum Syarak bagi mendakwa Responden tidak berhak menuntut harta sepencarian.
- 10.3 Tafsiran Hukum Syarak membuktikan bahawa perkahwinan yang difaraqkan berhak menuntut harta sepencarian.

10.4 Tafsiran harta sepencarian mempunyai ruang ijihad yang luas dan tidak semestinya setakat yang dikanunkan sahaja.

11) Pada asasnya dalam menimbangkan sesuatu tuntutan berkaitan harta sepencarian, dua persoalan yang diambil perhatian oleh Mahkamah ialah bahawa harta tersebut telah diperolehi dalam tempoh perkahwinan dan bahawa harta tersebut telah diperolehi bersama, sama ada dengan usaha bersama atau usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu. Dalam rayuan ini kami mendapati persoalan tentang usaha bersama dalam memperolehi harta yang dipertikaikan tidak berbangkit. Pihak-pihak hanya mempertikaikan berkaitan persoalan perkahwinan yang tidak wujud sejak dari awal yang sekaligus menyebabkan tidak berlaku perceraian. Berbeza situasinya dengan syarat yang ditetapkan dalam Seksyen 122 Enakmen undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 bahawa Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila **membenarkan lafaz talaq** atau apabila membuat suatu **perintah perceraian** untuk memerintah pembahagian harta sepencarian.

12) Pada prinsipnya, perceraian bukanlah satu-satunya syarat yang dijadikan sebagai asas dalam memfailkan tuntutan harta sepencarian kerana dalam keadaan tertentu undang-undang membenarkan tuntutan harta sepencarian difailkan tanpa adanya perintah berkaitan perceraian khususnya apabila melibatkan soal poligami sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 23(10) Enakmen undang-Undang Keluarga Islam. Begitu juga dalam keadaan jika berlaku kematian, pasangan yang masih hidup dibolehkan menuntut harta sepencarian, asalkan harta tersebut diperoleh dalam tempoh perkahwinan dan dengan usaha bersama pihak-pihak.

13) Untuk memahami isu dalam rayuan ini, kami berpendapat pihak-pihak perlu juga memahami konsep faraq nikah berdasarkan Hukum Syarak. Perkataan faraq adalah berasal daripada perkataan fa-ra-qa dan masdarnya ialah tafriq, yang bermaksud perkawinan yang dipisahkan/dibubarkan. Pada sudut istilah, faraq yang digunakan di dalam kitab-kitab fiqh membawa maksud pemisahan pernikahan yang dilakukan oleh mahkamah (Abdul Karim Zaidan. **Al Mufasssol Fi Ahkam Al Mar'ah Wa Baitul Muslim** (Beirut: Muassasah Risalah, 2000), hlm. 196). Perintah faraq nikah hanya boleh dibuat oleh mahkamah apabila berpuas hati bahawa sesuatu perkawinan itu adalah tidak sah. Nikah yang tidak sah adalah merujuk kepada nikah yang tiada atau hilang salah satu atau beberapa rukun atau syarat sah nikah (Wahbah Al-Zuhaily, **Fiqh dan Perundangan Islam, Jilid 7**, (terj. Ahmad Shahbari Salamon), (Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur, 2001), hlm. 159). Kesan daripada nikah yang tidak sah tersebut, maka Mahkamah boleh memerintahkan supaya perkahwinan tersebut difarapkan.

14) Dalam Mazhab Syafie terdapat istilah nikah fasid dan nikah batil, walau bagaimanapun hukum bagi kedua-duanya adalah sama (**Kitab Fiqh Ala Mazahibul Arbaah, Jilid 4, hlm. 109**)

والنكاح الفاسد هو ما اختل فيه شرط من الشروط المتقدمة، أما النكاح الباطل فهو ما اختل فيه ركن، وحكم الفاسد والباطل واحد في الغالب.

Apabila sesuatu pernikahan tersebut difarapkan, kesan atau hukum bagi pernikahan tersebut adalah tidak dikenakan had persetubuhan, diwajibkan iddah, disabitkan nasab keturunan dan diwajibkan membayar mahar mithil sebagaimana yang disebut juga dalam kitab yang sama.

هذا، والوطء بنكاح الشغار، والنكاح المؤقت، ونكاح المحرم بالنسك، ونكاح المرأة التي عقد عليها الولي لاثنين، لا حد فيه وتجب به العدة، ويثبت به النسب ومهر المثل.

15) Seterusnya kami juga merujuk **Kitab Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili Jilid 7, hlm. 112** yang menjelaskan bahawa wanita yang dipisahkan dari lelaki hasil pernikahan batil dan/atau fasid berhak mendapat mahar dan wajib melalui tempoh iddah seperti wanita yang diceraikan, manakala anak-anak yang terhasil daripada perkahwinan tersebut layak dibinkan, malah juga mewarisi harta peninggalan ayahnya.

16) Berdasarkan outoriti-otoriti tersebut kami berpendapat walaupun sesuatu pernikahan tersebut difarakkan, namun terdapat hak-hak yang diiktiraf oleh Hukum Syarak dengan mengambil kira bahawa kekhilafan pernikahan tersebut adalah sesuatu yang tidak disengajakan. Dalam rayuan ini, kami mendapati perkahwinan Perayu dan Responden telah difarakkan oleh Mahkamah pada 7 Julai 2014 melalui Permohonan No. 100005-010-2138-2013 iaitu selepas 24 tahun 5 bulan Perayu dan Responden hidup bersama sebagai pasangan suami isteri. Perkahwinan tersebut telah difarakkan oleh Mahkamah atas sebab masalah wali yang tidak diiktiraf perwaliannya oleh Hukum Syarak. Dalam masa yang sama, Mahkamah juga melalui kes no. 10005-006-1686-2015 telah mensabitkan bahawa enam orang anak yang lahir daripada perkahwinan tersebut adalah hasil wati' syubhah dan boleh dinasabkan kepada Responden. Dengan pensabitan wati' syubhah tersebut, pada hemat kami, Hakim Bicara telah membuat penilaian dan membuat dapatan bahawa kekhilafan pernikahan antara Perayu dan Responden adalah kekhilafan yang tidak disengajakan dan keputusan tersebut kekal tanpa ada rayuan daripada mana-mana pihak.

17) Dengan mengambil kira hak-hak yang diiktiraf oleh Hukum Syarak ke atas faraq nikah tersebut kami berpendapat Mahkamah juga dalam masalah ini boleh

mengiktiraf bahawa tempoh dari tarikh perkahwinan hingga ke tarikh perkahwinan tersebut difarapkan sebagai tempoh perkahwinan yang diiktiraf oleh undang-undang bagi maksud memfailkan tuntutan harta sepencarian. Ini kerana dalam tempoh tersebut pihak-pihak telah sama-sama berusaha memperoleh aset dengan kepercayaan dan anggapan bahawa perkahwinan mereka adalah sah. Kami juga berpendapat situasi ini juga adalah sama dengan soal penasaban anak sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 114, kesan daripada faraq nikah yang melibatkan persetubuhan syubhah. Walaupun perkahwinan yang difarapkan tersebut tidak wujud dari asalnya, namun Hukum Syarak dan undang-undang masih mengiktiraf hak-hak tertentu dari segi hukumnya yang mempunyai kesan yang sama seperti berlaku perceraian.

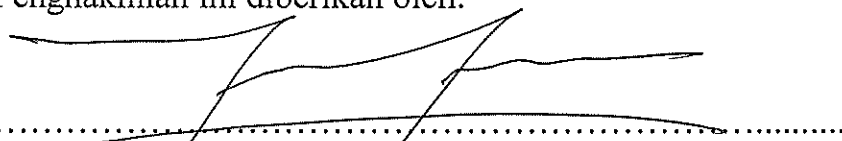
18) Seterusnya berkenaan dengan kos pula kami berpendapat oleh kerana rayuan Perayu adalah ditolak maka kos bagi rayuan ini wajar diberikan kepada Responden. Ini kerana rayuan ini telah melibatkan masa dan kos Responden untuk hadir dan melantik Peguam Syarie.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah Perayu dan Responden, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

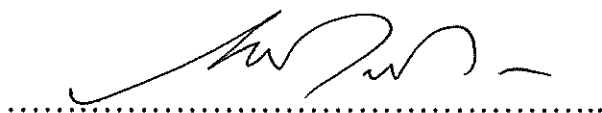
1. Rayuan Perayu adalah DITOLAK.
2. Perayu diperintahkan membayar kos prosiding bagi rayuan ini kepada Responden sebanyak RM1000.00.

Penghakiman ini diberikan oleh:



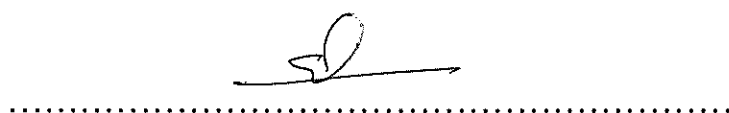
1. YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

